

1500834-83.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... pela Promotoria de Justiça por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico porque: a. em 5 de abril de 2022, por volta das 13h30, na Rua Cafelândia, 1680, Vila São Silvestre da Cruz, nesta cidade e comarca, guardavam e vendiam 20 invólucros plásticos contendo maconha e 10 eppendorfes de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500834-83.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500834-83.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

DANILO JESUS DOS REIS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

DANILO JESUS DOS REIS e ALEX RUAN DA SILVA DE SOUSA, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) no artigo 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06 porque: a. em 5 de abril de 2022, por volta das 13h30, na Rua Cafelândia, 1680, Vila São Silvestre da Cruz, nesta cidade e comarca, guardavam e vendiam 20 invólucros plásticos contendo maconha e 10 eppendorfes de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; b. Em data e local incertos, anteriormente a 5 de abril de 2022, associaram-se para praticar o crime de ato ilícito de entorpecentes.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 34), assim como o laudo de constatação (fls. 36/38) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 94/96).

Os(As) rés(us) foram notificados(as) (fls. 99 e 100) e apresentaram defesa preliminar (fls. 108/109). Em 27 de julho de 2022 ela(s) foi(ram) rejeitada(s), a denúncia recebida e designada audiência de instrução (fl. 110). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados(as) os(as) rés(us).

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

Os(As) rés(us) DANILO JESUS DOS REIS (Danilo) e ALEX RUAN DA SILVA DE SOUSA (Alex) foram denunciados(as) pela Promotoria de Justiça por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico porque: a. em 5 de abril de 2022, por volta das 13h30, na Rua Cafelândia, 1680, Vila São Silvestre da Cruz, nesta cidade e comarca, guardavam e vendiam 20 invólucros plásticos contendo maconha e 10 eppendorfes de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; b. Em data e local incertos, anteriormente a 5 de abril de 2022, associaram-se para praticar o

crime de ato ilícito de entorpecentes.

De acordo com a denúncia, policiais civis em diligência para investigação do tráfico de drogas viram que o réu Danilo vigiava e indicava a pessoas que se aproximavam dele a posição de Alex, alguns metros distante; essas pessoas então iam até ele e compravam entorpecentes, em seguida o réu Alex entregava o dinheiro obtido a Danilo. Realizada a abordagem, sob a posse do réu Alex foram encontrados os entorpecentes acima discriminados e sob a posse do réu Danilo foi encontrada a quantia de R\$22,00.

Concluída a instrução processual, compreendo que o Ministério Público se desincumbiu parcialmente do ônus que lhe cabia. A prova produzida em juízo, como determina o artigo 155 do Código de Processo Penal, para além de qualquer dúvida razoável, demonstra a materialidade e a autoria do crime de tráfico por parte dos réus.

Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico.

Ademais, em solo policial e em juízo as testemunhas Júlio Cezar e Flávio José declararam que são policiais civis e na data do fato, observaram dos dois réus traficando em via pública. Observaram que um deles ficava postado à frente, como a vigiar. Ele fazia o primeiro contato com os usuários e indicava o segundo homem, ao que os usuários iam até ele, entregavam dinheiro e recebiam algo em troca. Em dado momento, o segundo homem repassava o dinheiro para o primeiro. Realizaram a abordagem e de fato encontraram drogas sob a posse de um e dinheiro sob a posse de outro.

Em juízo, especialmente, questionado acerca de quem seria o primeiro homem e o segundo homem, o policial Flávio indicou o réu Danilo como aquele e o corréu Alex como este. Cuida-se de indicação que se adequa perfeitamente à confissão dos réus na fase policial, como exposto abaixo.

Essa descrição dos fatos feita pelos policiais é importante porque, no que diz respeito ao primeiro homem, poderia haver dúvida sobre a participação no crime de tráfico ou a prática dos crimes previstos nos artigos 35 ou 37 da Lei n. 11.343/03. Pelo fato de esse primeiro homem não atuar como olheiro, mas também receber efetivamente os usuários e encaminhá-los ao segundo homem, é possível inferir que este era efetivamente auxiliado por aquele na prática do tráfico de drogas, o que configura participação, a teor do artigo 29 do Código Penal.

Essa inferência restou confirmada pelos próprios réus, notadamente na fase policial. Danilo disse que fazia campana na "biqueira", incumbido de alertar sobre a chegada de policiais e encaminhar os compradores para o réu Alex, que efetivamente realizava a venda. Fazia dois meses que desempenhava essa tarefa no tráfico. Alex, por seu turno, disse que estava traficando, para receber R\$400,00 por dia.

Em juízo apenas o réu Alex voltou a confessar a prática do crime, mas o fez para negar o envolvimento do corréu Danilo, que negou o envolvimento com o tráfico. Segundo ele, foi ao local comprar drogas, mas como Alex não tinha troco, foi à padaria trocar o dinheiro, ocasião em que foi abordado por policiais.

Essa negativa não merece prosperar porque restou isolada nos autos, como visto de todas as provas juntadas aos autos. Não há qualquer razão para imaginar que os policiais tenham abordado e efetuado a prisão do réu Danilo à toa, não estando ele sequer com drogas para uso próprio. É posição pacífica da jurisprudência que o depoimento de policiais é tão válido e útil como qualquer outro depoimento, a depender do cotejo entre ele e as demais provas colhidas. Na espécie, os depoimentos dos policiais estão em harmonia entre si, com a confissão dos dois réus na fase policial e, ao menos em parte, com a confissão do réu Alex em juízo.

Embora o crime de tráfico de entorpecentes por parte de ambos os réus tenha sido cabalmente comprovado, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de demonstrar a prática do crime de associação para o tráfico de drogas por parte dos réus. É certo que os dois agentes traficavam em concurso, mas se mantinham um vínculo para além daquele momento, é conjectura. Danilo disse mesmo que atuava como olheiro fazia dois meses, mas isso não significa que ele atuasse somente com Alex.

Ele deu a entender que tinha um vínculo sim, mas com a "biqueira", não pessoalmente com o corréu. Caso tivessem sido angariadas comunicações entre os réus, relacionadas à atividade ilícita, evidenciando uma ligação estável entre eles com essa finalidade comum, poderia ser reconhecida a associação, mas somente o teor do relato de Danilo, que é réu, ressaltado, é pouco para fundamentar uma conclusão dessa.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que o crime de tráfico teve como objeto dupla diversidade de espécies de drogas. A quantidade total, 30 porções, não considero expressiva a ponto de desbordar a reprovabilidade ínsita à pena mínima. Considerando, portanto, somente a dupla variedade de entorpecentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão para o réu Alex. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Quanto ao réu Danilo, além da circunstância acima exposta, deve ser considerado o fato de que ostenta Maus antecedentes, pois foi condenado nos autos 0009054 92 2014, da 1ª Vara Criminal local, sentença que passou em julgado em 15/09/2015 (fl. 52). Em razão do exposto, para ele fixo a pena-base quanto ao crime de tráfico em 6 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a atenuante da confissão e para o réu Alex também a atenuante da menoridade de 21 anos. Assim, torno a pena do crime de tráfico ao mínimo.

O réu Danilo é reincidente, pois foi condenado por sentença transitada em julgado em 23/03/2018, nos autos 0002251 58 2016, da 1ª Vara Criminal local (fls. 51/52). Em razão da confissão, que no conjunto probatório é relevante, malgrado ela não tenha sido reafirmada em juízo, pois ele detalhou sua atuação e o tempo durante o qual se dedicou à mercancia ilícita, compenso a atenuante com a agravante.

Anoto que o réu também havia sido condenado pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Sorocaba, trânsito em julgado operado em 16/04/2018, nos autos 0025432 39 2015 (fls. 53/54), mas como se tratou de infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06, deixo de considerar o apontamento em desfavor dele, em atenção à jurisprudência do C.

STJ:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE.

1. À luz do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na questão de ordem no RE nº 430.105/RJ, julgado em 13/02/2007, de que o porte de droga para

consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, foi apenas despenalizado pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizado, esta Corte Superior vem decidindo que a condenação anterior pelo crime de porte de droga para uso próprio configura reincidência, o que impõe a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso I, do Código Penal e o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

2. Todavia, se a contravenção penal, punível com pena de prisão simples, não configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração, para fins de reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que conquanto seja crime, é punida apenas com "advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo", mormente se se considerar que em casos tais não há qualquer possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento, como no caso das penas substitutivas.

3. Há de se considerar, ainda, que a própria constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que está cercado de acirrados debates acerca da legitimidade da tutela do direito penal em contraposição às garantias constitucionais da intimidade e da vida privada, está em discussão perante o Supremo Tribunal Federal, que admitiu Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.659 para decidir sobre a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal.

4. E, em face dos questionamentos acerca da proporcionalidade do direito penal para o controle do consumo de drogas em prejuízo de outras medidas de natureza extrapenal relacionadas às políticas de redução de danos, eventualmente até mais severas para a contenção do consumo do que aquelas previstas atualmente, o prévio apenamento por porte de droga para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei de Drogas, não deve constituir causa geradora de reincidência.

5. Recurso improvido."

(STJ – 6ª T., REsp 1672654 / SP – rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.08.2018, grifo não original)

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase para o réu Danilo, pois ele é reincidente, ostenta antecedentes e atuava no tráfico fazia ao menos dois meses.

Quanto ao corréu Alex, negaria o benefício do §4º porque ele já foi preso em flagrante pouco antes do fato sob exame, acusado de tráfico. Todavia, a 3ª Seção do STJ pacificou que ações penais e inquéritos em curso não servem para afastar a causa de diminuição: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/2006". A conclusão pela dedicação a atividades criminosas é legítima se decorrer de provas dos autos, o que não é o caso. Danilo disse que atuava fazia dois meses como olheiro do tráfico, mas Alex não deu esse detalhe, nem foi demonstrado por outros meios que ele fosse dedicado ao ilícito.

Portanto, para o corréu Alex, na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não tem maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal, que é o que mais beneficia o réu, entendo por bem proceder à redução em 2/3, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 ano e 8 meses de reclusão.

As penas ficam assim consolidadas:

Para o réu Danilo 6 anos e 3 meses e 625 dias-multa; para o réu Alex, 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa para o crime de tráfico.

Sendo os(as) rés(us) Alex primários(as) e não tendo maus antecedentes, poderão iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição pessoal em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo

período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele.

O réu Danilo é reincidente e tem maus antecedentes, deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado e considerada a detração do tempo de prisão provisória, ainda assim ele não tem direito à fixação de regime inicial mais benéfico.

Considerando que o valor do dia-multa deve seguir a condição econômico-financeira dos(as) réus(us) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

1. Condenar o réu DANILO JESUS DOS REIS como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 ao cumprimento de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão no regime inicial fechado e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

2. Condenar o réu ALEX RUAN DA SILVA DE SOUSA, como incurso(a) no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, o que é substituído por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

2. Absolver os dois réus acima da imputação de terem praticado o crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Considerando a reincidência específica dos(as) réus(és) Danilo, é de se supor que sua liberdade representa risco à ordem pública, por isso não é adequado que possam recorrer em liberdade. Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontram.

Ao corréu Alex concedo a liberdade provisória, considerando que é primário e ante a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento dos valores apreendidos em razão da ausência de comprovação clara da origem lícita deles, do que se depreende que consistem em produto de crime. Oficie-se.

Não sendo mais útil ao deslinde da causa, defiro a destruição dos objetos apreendidos junto com os entorpecentes. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos(as) réus(us) no rol dos culpados e informe-se a Justiça Eleitoral para que aplica a pena de suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA